

1500223-85.2022.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500223-85.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Reqte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

DENNYS DANIEL GUEDES MARCOS, DIOGO GONCALVES ALVES e MARCELO HENRIQUE LIMA PRUDENCIO

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

MARCELO HENRIQUE LIMA PRUDÊNCIO, DIOGO GONÇALVES ALVES e DENNYS DANIEL GUEDES MARCOS, já qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua Manoel Francisco Lisboa, Belas Artes, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 691 (seiscentos e noventa e um) supositórios de crack, derivado da cocaína, 244 (duzentos e quarenta e quatro) "trouxinhas de papel" de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha, 134 (cento e trinta e quatro) porções de cocaína, 12 (doze) porções de Skunk, derivado da maconha e 34 (trinta e quatro) frascos da droga cloreto de metileno/diclorometano, conhecida por lança-perfume, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 9.02.2022 (pág. 122).

Os réus foram citados (págs. 134, 137 e 140) e apresentaram resposta escrita à acusação (págs. 150/155).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e,

ao final, foram realizados os interrogatórios dos réus (págs. 195/197).

Os laudos de exame químico-toxicológico foram juntados aos autos às págs. 183/186.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-se os acusados nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em relação ao acusado Dennys que seja absolvido e subsidiariamente, reconhecido o tráfico privilegiado, aplicando-se o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, bem como seja determinado o cumprimento de pena no regime aberto. Ao passo que em relação aos acusados, Marcelo e Diogo, que sejam absolvidos e, subsidiariamente, seja reconhecia a minorante da confissão e, caso entenda pela condenação dos acusados, que seja considerado as circunstancias judiciais favoráveis e a pena fixada no mínimo legal e que os denunciados possam apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 03/04), pelo boletim de ocorrência (págs. 11/13), pelo auto de exibição e de apreensão (págs. 15/17), pelo auto de constatação preliminar (págs. 18/19), pelo laudo químico- toxicológico (págs. 183/186), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e atribuída aos acusados.

A testemunha arrolada pela acusação, Anderson Alves, ouvido em Juízo, Policial Civil, disse que foram ao local dos fatos conhecido como ponto de vendas de drogas e fizeram campana com uma viatura descaracterizada e puderam observar a atuação dos três acusados, sendo que enquanto Marcelo ficava abaixado, Diogo e Dennys efetuavam a comercialização das drogas, motivo pelo qual foram abordados. Informou que com o Marcelo fora encontrada grande quantidade de drogas e um pouco menos de R\$ 100,00 (cem reais). Esclareceu que os acusados confessaram informalmente a prática delitiva. Afirmou que nunca os viu anteriormente aos fatos.

A testemunha arrolada pela acusação, José Ricardo Garcia Louzada, ouvido em Juízo, Policial Civil, apresentou os mesmos fatos que seu colega de profissão.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"A alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar os réus. Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para infirmá-las. 'O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm

o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câ. V.U.

31.07.2008)'. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Aferes-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

O réu, Marcelo Henrique Lima Prudêncio, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que atuava na traficância há 01 (uma) semana. Relatou que os outros dois acusados (Dennys e Diogo) eram usuários, mas que ofereceu R\$ 30,00 (trinta reais) para Diogo ajudar com os clientes, organizando a fila. Afirmou que Dennys foi ao local somente para comprar drogas.

O réu, Diogo Gonçalves Alves, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que é usuário e na data dos fatos foi ao ponto comprar entorpecentes, mas acabou aceitando R\$ 30,00 (trinta reais) que fora oferecido por Marcelo para que o ajudasse com os clientes que estavam aguardando na fila. Afirmou que nunca havia comprado drogas com ele antes.

O réu, Dennys Daniel Guedes Marcos, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que o Marcelo era o traficante e o Diogo estava organizando a fila. Afirmou que é usuário e foi ao local apenas para comprar maconha, negou a traficância. Esclareceu que nunca havia comprado drogas com o Marcelo.

Pois bem.

Embora tenha o corréu Dennys negado a traficância, sua versão não merece arrimo em vista dos depoimentos colhidos em Juízo, em que os policiais afirmaram que foi possível vê-lo juntamente com os outros dois acusados atuando na prática de

comercialização de drogas.

Desse modo, tem-se que a responsabilidade penal dos réus é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos e a confissão espontânea dos acusados Marcelo e Diogo, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no

artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. – Recurso conhecido e provido.” (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

“Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor dos réus.

Passo a dosar a pena.

RÉU MARCELO HENRIQUE LIMA PRUDÊNCIO

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 74) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]” (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea

e a menoridade relativa, entretanto, a pena não poderá ficar aquém do mínimo legal por força da súmula nº 231 do STJ, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O tráfico privilegiado consiste em punir com menor severidade o "traficante de primeira viagem", ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, contudo, o acusado não faz jus a este redutor, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da existência de ato infracional equiparado a tráfico de drogas, que, portanto, demonstra que o acusado efetivamente se dedica as atividades criminosas de modo reiterado e, desse modo, inviável tal benesse.

Nesse sentido, em consonância tem a jurisprudência decidido:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, tal como na espécie, notadamente diante da manutenção da circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 488.570/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/8/2019).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o recorrente se dedica costumeiramente a atividades criminosas. Tal conclusão encontra-se amparada em documentos que reportam os atos infracionais praticados pelo recorrente quando ainda era menor de idade, bem como na quantidade de droga apreendida e no fato dos policiais terem ressaltado a existência de inúmeras denúncias dando conta do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, além do que, durante a breve observação que realizaram no dia dos fatos, visualizaram no em negociação com três pessoas diferentes, tudo a reforçar a convicção quanto a sua dedicação intensa e exclusiva ao exercício dessa atividade criminosa. Desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado

revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de atos infracionais anteriores, apesar de não configurar maus antecedentes ou induzir reincidência, pode indicar a dedicação do agente a práticas delitivas, como na espécie, constituindo fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1812378/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/4/2021).

Assim, segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉU DIOGO GONÇALVES ALVES

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 69/71) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei

n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, como também a agravante da reincidência, conforme certidão (págs. 72/73), que é considerada preponderante sobre a atenuante conforme regra expressa do artigo 67 do Código Penal. Diante disso, exacerbo a pena base em apenas 1/3 (um terço), resultando uma pena provisória de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu sendo reincidente impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Dito isso, presente a agravante da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), pela suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I e III do Código Penal), e a aplicação dos regimes aberto e semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal).

Assim, também o regime inicial de cumprimento será o fechado.

RÉU DENNYS DANIEL GUEDES MARCOS

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág.

77) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de menoridade relativa, entretanto, a pena não poderá ficar aquém do mínimo legal por força da súmula nº 231 do STJ, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O tráfico privilegiado consiste em punir com menor severidade o "traficante de primeira viagem", ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, contudo, o acusado não faz jus a este redutor, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da existência de ato infracional equiparado a tráfico de drogas, que, portanto, demonstra que o acusado efetivamente se dedica as atividades criminosas de modo reiterado e, desse modo, inviável tal benesse.

Nesse sentido, em consonância tem a jurisprudência decidido:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato

infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, tal como na espécie, notadamente diante da manutenção da circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 488.570/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJE 23/8/2019).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o recorrente se dedica costumeiramente a atividades criminosas. Tal conclusão encontra-se amparada em documentos que reportam os atos infracionais praticados pelo recorrente quando ainda era menor de idade, bem como na quantidade de droga apreendida e no fato dos policiais terem ressaltado a existência de inúmeras denúncias dando conta do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, além do que, durante a breve observação que realizaram no dia dos fatos, visualizaram no em negociação com três pessoas diferentes, tudo a reforçar a convicção quanto a sua dedicação intensa e exclusiva ao exercício dessa atividade criminosa. Desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de atos infracionais anteriores, apesar de não configurar maus antecedentes ou induzir reincidência, pode indicar a dedicação do agente a práticas delitivas, como na espécie, constituindo fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1812378/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/4/2021).

Assim, segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim

como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto, CONDENO o réu MARCELO HENRIQUE LIMA PRUDÊNCIO qualificado nos autos, ao cumprimento, 05 (cinco) anos de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO o réu DIOGO GONÇALVES ALVES qualificado nos autos, ao cumprimento 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa., no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO o réu DENNYS DANIEL GUEDES MARCOS qualificado nos autos, ao cumprimento, 05 (cinco) anos de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Recomende-se os réus na prisão em que se encontram, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder dos réus em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se os réus para efetuar o pagamento da multa.

Condene-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Arbitre os honorários dos defensores nomeados, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 04 de julho de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA